

1500343-61.2021.8.26.0623

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaní Cristina Mendes Marum

Comarca: São João da Boa Vista

Foro: Foro de São João da Boa Vista

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... a alegação de estarem realizando o tráfico de drogas.

Afirmou que já foi preso por tráfico de drogas, porém, ao ganhar a liberdade não mais tornou a realizar o tráfico. Asseverou que desconhecia as porções de drogas apresentadas na delegacia, e ressaltou que os entorpecentes não estavam em seu poder (fls. 8).

Em juízo, o réu manteve suas negativas quanto à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São João da Boa Vista

Foro de São João da Boa Vista

Vara Criminal

Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2150, São João da Boa Vista-SP - cep 13874-149

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500343-61.2021.8.26.0623 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500343-61.2021.8.26.0623

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2310456/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 21390016 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 4403/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2310456 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN RODRIGUES DE AQUINO APOLINÁRIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaní Cristina Mendes Marum

Vistos.

RYAN RODRIGUES DE AQUINO APOLINÁRIO foi denunciado como incurso nas penas dos

artigos 33 e 35, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, em razão de desde data anterior até o dia 14 de novembro de 2021, em horário incerto, na Praça Rui Barbosa, 1 - Centro, nesta cidade e Comarca, ter se associado com o adolescente Kaycky Alexsander Ribeiro de Assis, para o fim de praticar, reiteradamente, crime previsto no art. 33, "caput", da lei nº 11.343/06.

Consta ainda que, no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 17h40min, na Praça Rui Barbosa, 1 - Centro, nesta cidade e Comarca, o acusado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Kaycky, durante estado de calamidade pública advindo da pandemia da COVID-19, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta e duas porções de "crack" pesando 13,3g, substância essa que causa dependência física e psíquica.

O réu foi preso em flagrante, sendo sua custódia convertida em prisão preventiva.

O acusado foi notificado e depois de apresentar defesa preliminar, foi a denúncia recebida em 29 de março de 2022, sendo determinada a citação do réu.

No curso da instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, com a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e a absolvição do acusado, no que diz respeito ao delito de associação.

A Defensoria, a seu turno, pleiteou a absolvição do acusado com relação a ambos os crimes a ele atribuídos e requereu, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no artigo 28 da Lei de Tóxicos, e postulou, subsidiariamente, pela aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

Na ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado negou os fatos que lhe foram atribuídos e sustentou que foi convidado pelo seu amigo Kaycky para que fossem até o centro da cidade, onde ele lhe pagaria um sorvete. Informou que saíram do Bairro Recanto do Jaguari, e no trajeto para o centro passaram pela Estação Ferroviária.

Sustentou que quando saíram da estação, visualizaram a viatura policial, tendo Kaycky saído em fuga, enquanto que o interrogando continuou caminhando normalmente. Mencionou que foi abordado e que nada de ilícito encontrado em seu poder. Disse que momentos depois, tanto o interrogando quanto Kaycky foram apresentados no plantão policial, sob a alegação de estarem realizando o tráfico de drogas.

Afirmou que já foi preso por tráfico de drogas, porém, ao ganhar a liberdade não mais tornou a realizar o tráfico. Asseverou que desconhecia as porções de drogas apresentadas na delegacia, e ressaltou que os entorpecentes não estavam em seu poder (fls. 8).

Em juízo, o réu manteve suas negativas quanto à traficância, mas modificou parcialmente sua versão, alegando, desta feita, que se encontrou com o adolescente Kaycky no bairro Recanto do Jaguari, tendo lhe perguntado se ele tinha uma pedra de "crack" para lhe vender, tendo o adolescente respondido que não, e que somente

tinha droga na estação.

Mencionou que Kaycky o convidou para ir à estação e disse que ao chegarem em tal local, ele pegou o entorpecente, e quando o jovem chegava à praça, a polícia os abordou. Comentou que ficou parado, mexendo em seu celular, tendo os policiais lhe perguntado onde estava a droga, ao que respondeu que não tinha nenhuma droga.

Sustentou que não jogou nada no chão e disse que não chegou a comprar a droga de Kaycky, e que pretendia comprar o entorpecente fiado. Alegou que acredita que tenha sido acusado porque o policial Ponciano não gosta do interrogando. Informou que não estava junto com Kaycky no momento da abordagem, sendo certo que o adolescente estava “quase chegando perto de mim” quando a polícia chegou, tendo o menor corrido.

Alegou que não tinha em seu poder nenhum objeto para o consumo de droga, e mencionou que pretendia usar o entorpecente no meio do mato, e que lá mesmo encontraria os apetrechos para consumo do entorpecente. Informou que costumava comprar droga do adolescente Kaycky, tendo o mesmo, naquela data, dito que a droga dele estava no centro e que precisaria ir buscá-la na estação.

Comentou que no local, Kaycky parou para conversar com outra pessoa, enquanto o interrogando se dirigiu à praça e disse que não chegou a vê-lo com uma sacola na mão. Aduziu que no local não viu ninguém vendendo drogas e disse que não chegou a pegar nenhuma sacola nas mãos. Informou que já foi anteriormente preso por tráfico e que naquela ocasião assumiu a droga que era sua. Alegou ser somente usuário de entorpecente (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Todavia, as negativas do acusado, além de pouco convincentes, restaram contrariadas pela prova produzida no processo.

O policial André Ponciano das Chagas narrou que na data dos fatos foi acionado pelo Copom, sendo informado que dois indivíduos estavam praticando o tráfico perto da linha férrea. Mencionou que foi realizado cerco no local e que na Rua Marechal Deodoro visualizou dois indivíduos com as características descritas pelo Copom, sendo certo que ao ingressar na linha férrea, eles perceberam a presença da equipe, tendo o réu dispensado algo ao solo.

Aduziu que os indivíduos foram abordados, e comentou que em poder do jovem Kaycky somente foram encontrados um celular e dinheiro. Informou que ao abrir o invólucro dispensado pelo réu, constatou-se que nele havia pedras de “crack”, sendo o acusado e o adolescentes conduzidos à UPA e depois à delegacia para apresentação da ocorrência.

Alegou que o acusado e o adolescente estavam recebendo dinheiro e entregando porções e disse que os outros indivíduos que estavam no local não puderam ser capturados, sendo possível abordar somente o réu e o adolescente porque eles estavam mais próximos. Informou que o acusado tem várias passagens por tráfico, inclusive quando era menor de idade, já tendo o depoente o detido em outras ocasiões, pela prática de tráfico.

Mencionou que o adolescente também foi abordado depois dos fatos, pela prática do tráfico e disse que havia denúncias de que ele e o réu traficavam no bairro Recanto do Jaguari, e que foram prestadas por populares, que tinham medo de se identificar. Comentou que as drogas estavam embaladas separadamente, dentro de um invólucro e disse que não foram encontrados objetos para consumo de drogas.

Aduziu que não se recorda de como o dinheiro se apresentava e disse que o réu e o adolescente não pareciam drogados, havendo no local, além deles, mais uma pessoa que conseguiu se evadir. Informou que conforme a denúncia, o réu e o jovem

comercializavam drogas naquele local, para pessoas que ali paravam, e informou que já os viu anteriormente juntos no Bairro Recanto do Jaguari, mas não os viu traficando, porque senão seriam presos em flagrante (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

O policial Ricardo Henrique Costa, a seu turno, narrou que foi acionado pelo Copom, em razão de denúncia de tráfico na estação rodoviária, que estaria sendo praticado por dois indivíduos, um dos quais estava vestindo uma camiseta de cor azul, de time de futebol, com o numeral 10, enquanto que o outro estava com uma camiseta branca.

Salientou que foi ao local indicado, onde avistou os dois indivíduos, os quais se separaram quando perceberam a aproximação da polícia. Disse que o acusado fugiu e dispensou um invólucro contendo trinta e duas pedras de "crack" e comentou que o adolescente foi abordado por outra equipe, com ele sendo encontrados somente R\$ 146,00.

Destacou que o réu não portava dinheiro e informou que ele e o adolescente alegaram que apenas estavam de passagem pelo local. Disse que não viu nenhum contato do réu ou do jovem com terceiros, e comentou que eles não aparentavam estar drogados e nem portavam objetos para o consumo de drogas, tendo o acusado negado a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Mencionou que o adolescente e o acusado já eram conhecidos nos meios policiais e informou que não chegou a ser realizada campana, tendo somente sido feito o cerco ao local (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

E o adolescente Kaycky, quando ouvido na fase policial, relatou que resolveu vir com o acusado ao centro da cidade, pois o declarante iria pagar um sorvete ao réu. Alegou que estava em poder das pedras de "crack" e disse que no trajeto até o centro, próximo à Estação das Artes, foram abordados pela polícia, sendo encontrados em seu poder a droga e o dinheiro, que era proveniente do tráfico. Sustentou que as porções de "crack" estavam no interior de sua mão, e que ao avistar a Polícia Militar, acabou dispensando-as ao solo (fls. 7).

Diante de tais relatos, e considerando que além de no dia dos fatos ter sido recebida denúncia de tráfico contra pessoas com as mesmas vestimentas usadas pelo acusado e pelo adolescente, ambos foram vistos no local dos fatos, e ao notarem a aproximação da polícia, o réu dispensou no solo um invólucro, que se constatou conter trinta e duas pedras de "crack", individualmente embaladas e prontas para a venda a terceiros, é de se concluir que restou confirmada a traficância atribuída ao réu e ao adolescente.

Esse entendimento se justifica porque além da quantidade e variedade das drogas apreendidas, que poderiam abastecer mais de três dezenas de usuários, ser incompatível com a que poderia se destinar ao consumo do réu e do adolescente, estes não aparentavam estar drogados e nem portavam objetos para consumo de drogas, sendo encontrado dinheiro em poder do adolescente, o qual, aliás, confessou a prática da traficância e admitiu que o numerário era produto do ilícito comércio, sendo comum que em caso de concurso de agentes, um dos traficantes fique incumbido de receber e guardar o dinheiro recebido dos compradores, enquanto o outro se responsabiliza pela posse das drogas.

Embora um dos milicianos tenha dito que foi realizada observação antes da abordagem, e que o réu e o jovem foram vistos mantendo contatos com terceiros, tendo o outro policial relatado que foi realizado apenas o cerco ao local, e que não viu nenhum contato do réu e do adolescente com terceiros, ambos os policiais apresentaram versão uníssona no tocante ao recebimento de denúncias de tráfico contra pessoas com as características do réu e do adolescente, bem como afirmaram, de modo unânime, que viram o réu dispensar a droga no chão.

E as divergências entre os depoimentos prestados não têm o condão de invalidá-los, notadamente porque no que tange aos aspectos essenciais dos fatos e notadamente a visualização do réu dispensando no chão o invólucro que continha a droga, os depoimentos foram coerentes.

Nesse sentido, o seguinte aresto:

“TÓXICO - Tráfico - Prova criminal - Testemunhas - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Pequenas divergências que não se mostram como razões bastantes para se desprezar esse meio de prova - Palavras dos policiais que presenciaram a apreensão da droga - Conjunto probatório suficiente para a condenação - Pretensão de desclassificação para o delito previsto no artigo 16 da Lei nº 6.368/76 - Impossibilidade - Tráfico caracterizado - Recurso não provido.” (TJSP - Ap. Crim. nº 265.421-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal de Janeiro/99 - Rel. Debatin Cardoso - J. 21.01.99 - v.u).

Ainda que o acusado tivesse feito restrições ao depoimento do policial André, ele informou que não conhecia o miliciano Ricardo, não se vislumbrando motivos para que este policial o tivesse incriminado de forma injusta e indevida, atribuindo-lhe crime de que o sabem inocente e que simplesmente tivesse inventado a versão de que viu o acusado dispensar as pedras de “crack”.

Outrossim, ainda que o adolescente tenha procurado assumir sozinho a prática do tráfico e a posse da droga, isentando o réu de responsabilidade, a versão que ele apresentou foi contrariada pelo depoimento de ambos os policiais, os quais, como dito, viram o réu e não o adolescente dispensar a droga no chão, não prosperando por todos esses motivos o pedido de absolvição formulado pela Defesa.

E mesmo que o réu também fosse usuário de entorpecentes, tal fato não elide a traficância a ele atribuída, porquanto não são raros os casos de usuários que também se dedicam ao tráfico, como forma de manter o próprio vício e de conseguir dinheiro sem esforço, pelo que não prospera a solução desclassificatória almejada pela Defensoria.

Observo, ainda, que apesar das testemunhas de acusação serem policiais militares, tal fato não pode servir para elidir a condenação do acusado, uma vez que:

“Seria verdadeiro contra-senso que, aos agentes de segurança, deferisse o ordenamento jurídico determinada tarefa, para, depois, negar, aprioristicamente, valor a seus testemunhos, quando dela viessem prestar contas (TACRIM/SP, AC -Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 92/352)”.

No que diz respeito à causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, também restou ela devidamente confirmada, já que além das denúncias de tráfico contra pessoas com as mesmas vestimentas do réu e do adolescente, ambos foram vistos juntos no local dos fatos, havendo, inclusive, divisão de função entre eles, já que incumbiu ao réu a posse da droga e ao jovem a posse do dinheiro produto da traficância.

Provada a autoria do tráfico, a materialidade delitiva restou confirmada pelo laudo de fls. 83/84.

Todavia, os elementos constantes dos autos são insuficientes para a caracterização, com certeza, do crime de associação.

E isso se justifica porque pelo que se depreende dos relatos, não há notícias de que tenha sido realizada alguma outra diligência para confirmação de que essa situação de associação entre o réu e o adolescente para o ilícito comércio se

repetia com frequência e com estabilidade, pelo que merece o acusado ser absolvido quanto à imputação de ter cometido o delito descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, não podendo a mera coautoria ser confundida com a associação.

Nesse sentido, confirmam-se as seguintes lições de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi (Lei de Drogas Anotada – Lei 11.343/2006, 1a ed., São Paulo, Saraiva, p. 120):

“Poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível, prevista naqueles artigos, para a incidência do delito agora comentado, em virtude da cláusula 'reiteradamente ou não'. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria.”

Passo à fixação da pena.

Extraí-se dos autos que apesar de registrar condenação pelo crime de tráfico, como a mesma transitou em julgado depois dos fatos (fls. 42 - processo 1500234-81), o réu é tecnicamente primário, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor diário mínimo, no tocante ao tráfico.

Na segunda fase de dosimetria da reprimenda, reconheço a menoridade do réu como circunstância atenuante, mas deixo de proceder à correspondente diminuição, porquanto a pena-base já foi fixada no mínimo legal, e porque nesta etapa, não cabe a redução da sanção aquém do patamar previsto em lei.

Não merece ser reconhecida a agravante descrita no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, pois não restou comprovado que o acusado se aproveitou das circunstâncias de vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de pandemia para perpetrar o crime em questão, de modo que não havendo nexos causal entre a situação de pandemia e a conduta do acusado, deve ser afastada a agravante em questão.

Na terceira fase de fixação da pena, como o ilícito comércio era praticado juntamente com adolescente, conforme acima exposto, e presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, majoro a sanção em um sexto, perfazendo cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Deixo de proceder à redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque apesar de tecnicamente primário, o réu já foi condenado pela prática do tráfico (fls. 42), e depois do cometimento daquele delito veio a se envolver no crime em tela, revelando tais fatos a reiteração delitiva e o seu envolvimento no meio criminógeno e em atividades delitivas, pelo que o réu não preenche os requisitos subjetivos para obter a redução da reprimenda.

Ante a reiteração delitiva do réu, a gravidade do delito em tela, que é equiparado a hediondo, sendo o “crack”, ainda, droga de maior potencial lesivo, podendo as drogas apreendidas, como dito, abastecer mais de três dezenas de usuários, o que revela maior gravidade concreta da conduta, e tendo em vista que o tráfico constitui inegável fonte de outros tipos de criminalidade, e que põe em risco a ordem pública, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o acusado iniciar o cumprimento de

sua reprimenda do crime de tráfico em regime fechado, observando-se que a custódia do réu, além de garantir a aplicação da lei penal, também se destina a resguardar a ordem pública, prevenindo que em liberdade, volte a se envolver no ilícito comércio.

Observa-se, ainda, que no tocante à detração do período em que o réu já permaneceu preso, o mero cumprimento do lapso temporal não é suficiente para a concessão de regime prisional mais brando, já que isso equivaleria à verdadeira progressão de regime feita sem a análise do necessário requisito subjetivo, sendo mais adequado que em sede de execução, o acusado comprove o preenchimento de seu mérito e lá postule eventual progressão de regime a que considere ter direito.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR RYAN RODRIGUES DE AQUINO APOLINÁRIO como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. Fixo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei.

Outrossim, ABSOLVO o acusado da imputação de ter cometido o delito do artigo 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Estando o réu encarcerado, e tendo em vista a quantidade da pena e o regime prisional impostos, a sua reiteração delitiva e os demais motivos acima expostos, e que ora reitero, não lhe concedo o direito de apelar desta sentença em liberdade. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra, oficiando-se.

Oportunamente, oficie-se ao IIRGD e ao cartório eleitoral, bem como expeça-se guia de recolhimento.

Tendo em conta que os elementos constantes dos autos denotam que o dinheiro apreendido é proveniente da traficância (mesmo porque não foi comprovada sua origem lícita), decreto o perdimento do numerário, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Todavia, como não se comprovou que o celular também fosse usado para a traficância, defiro sua restituição ao réu.

Custas, na forma da lei, ressalvada sua exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50, ficando deferidos ao réu os benefícios da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

São João da Boa Vista, 26 de novembro de 2022.

Elaní Cristina Mendes Marum
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA